

1521824-04.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... contendo a contabilidade do tráfico. Cumpre reconhecer, também, que a quantidade de drogas apreendidas não é significativa para determinar que era destinada ao tráfico: 8,2g de maconha e 3,5g de cocaína. Considerando tratar-se de delito de tráfico, não basta a apreensão do entorpecente, mas deve haver comprovação de que este se destinava ao consumo de terceiros. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1521824-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246929/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20168094 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3206/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2246929 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 16 de novembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Cássio Roberto Conserino e o réu WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE, acompanhado da Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Presentes as testemunhas Jatniel Lima dos Santos (PC) e MARIVALDO DE ARAÚJOL (PC). O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foram então ouvidas as testemunhas

presentes, cujos depoimentos foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Em seguida, o réu foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com a Defensora Pública que o assiste antes da realização do ato. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Dra. Defensora Pública, pelo réu, foi dito: MM. Juiz, o réu WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE foi denunciado e está sendo processado por suposta infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. A acusação não merece prosperar, pois, pelo que se vislumbra dos elementos de prova coligidos nos autos, não há uma base sólida a sustentar um decreto condenatório no presente caso. O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, não tinha nenhum entorpecente em sua posse; os policiais civis o abordaram dizendo que tinham um vídeo que mostrava imagens dele traficando e pediram R\$ 8.000,00 para liberá-lo. A versão projetada pelo réu merece credibilidade, pois não restou infirmada pelo conjunto probatório carreado aos autos. De fato, a prova que pesa em desfavor do acusado ficou limitada aos precários depoimentos prestados pelos policiais civis atuantes na ocorrência. É de se ressaltar, nessa toada, que as palavras isoladas das referidas testemunhas são insuficientes para dar suporte a um decreto condenatório. Com efeito, os policiais não viram nenhum ato típico de traficância. Ainda, os depoimentos judiciais dos policiais apresentaram contradições e, portanto, não trouxeram segurança para o conjunto probatório, como bem ressaltou o Ministério Público. Nesse sentido, vale apontar que o policial Marivaldo aduziu que tinham as características do acusado e isso teria levado à abordagem. Ocorre que o policial Jatniel, diversamente, disse que teriam visto diversas pessoas se aproximando do acusado, circunstância que sequer havia sido relatada na delegacia. Como se não bastasse, enquanto o policial Marivaldo afirmou que outras pessoas também foram abordadas no dia, o seu colega Jatniel não se lembrou de terem abordado outros indivíduos. Frise-se, ainda, que não foram apreendidas as comuns anotações contendo a contabilidade do tráfico. Cumpre reconhecer, também, que a quantidade de drogas apreendidas não é significativa para determinar que era destinada ao tráfico: 8,2g de maconha e 3,5g de cocaína. Considerando tratar-se de delito de tráfico, não basta a apreensão do entorpecente, mas deve haver comprovação de que este se destinava ao consumo de terceiros. Conclui-se, portanto, que é manifesta a precariedade das provas produzidas no presente feito, de modo que a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, no caso de entendimento diverso, em nome do princípio da eventualidade, pleiteia-se, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06, uma vez não demonstrado que a droga era destinada ao consumo de terceiros. Vale ressaltar, nesse passo, que, para o estabelecimento da tipicidade correta, é necessário analisar todo o conjunto de circunstâncias que envolvem o caso concreto. Se houver dúvida quanto à tipificação do fato, como na hipótese em análise, o magistrado deve optar pela que for mais benéfica ao réu. Derradeiramente, postula-se seja reconhecido o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Nessa toada, a reincidência, por si só, não obsta a aplicação da citada causa de diminuição da reprimenda. Com efeito, a negativa de aplicação da minorante apenas em função da reincidência (no caso, não específica) importa ofensa aos princípios da proporcionalidade e do "non bis in idem". Se primário, ao réu seria possível a fixação de pena mínima no importe de um ano e oito meses de reclusão. Ao reincidente, entretanto, a pena mínima seria equivalente a cinco anos de reclusão. A desproporcionalidade das sanções, portanto, é evidente, especialmente se atentarmos para o fator de discriminação eleito, a saber, a reincidência. Isso porque a reincidência, nos demais crimes, importa, usualmente, em elevação da pena no montante de 1/6 (um sexto). Logo, não há razão para que no caso do tráfico de entorpecentes seja estabelecida uma diferença superior a 300% (trezentos por cento) entre primários e reincidentes. Além disso, a consideração da reincidência em dois

momentos, no primeiro para elevar a reprimenda, no segundo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, caracteriza a figura do "bis in idem", o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Assim, postula-se seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Por fim, que seja fixado regime prisional diverso do fechado. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença nos termos seguintes: WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 13h03min, no Largo do Paissandú, altura do nº 10, República, nesta Capital, trazia consigo e guardava 09 (nove) papelotes contendo Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido de 8,2g (oito gramas e dois decigramas), e 04 (quatro) papelotes contendo cocaína, com peso líquido de 3,5g (três gramas e cinco decigramas), substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a inicial acusatória, na data e local dos fatos, policiais civis realizavam diligências com o espoco de reprimir o tráfico de drogas e a prática de outros delitivos em meio a semáforos e cruzamentos de grande fluxo, quando se depararam com o denunciado e o abordaram. Em revista pessoal, os policiais localizaram no interior de uma sacola plástica que o denunciado trazia consigo as porções de entorpecentes acima descritas, bem como a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais), distribuída em cédulas de pequena monta (R\$ 10,00 e R\$ 5,00). Questionado, o denunciado nada disse aos policiais. De acordo com a denúncia, neste contexto, foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, onde permaneceu em silêncio quando formalmente interrogado. Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva. Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado pessoalmente, após o que a Defensoria Pública apresentou defesa prévia, às fls. 96-97. Às fls. 98-100, foi juntado o Laudo de Exame Químico-toxicológico definitivo nº 303.258/2021. O recebimento da denúncia foi mantido e o acusado citado. Instalada audiência no dia 09 de março de 2022, os policiais civis, únicas testemunhas, não ingressaram, fato ao qual a defesa não deu causa, motivo pelo qual, na ocasião, foi revogada a prisão preventiva (fls. 142-144). Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas Policiais Civis Marivaldo de Araújo e Jatniel Lima dos Santos. Por último, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais. É o relatório. Fundamento e Decido. Da análise do feito, verifica-se a procedência parcial do pedido formulado na denúncia, impondo-se a desclassificação da imputação inicial para o delito de uso de substância entorpecente, na forma do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Cuida-se de ação penal proposta contra WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE, que é apontado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Ocorre, porém, que não há nos autos prova de envolvimento do acusado com o narcotráfico e, tampouco, que na ocasião dos fatos estivesse no exercício da traficância. Destaque-se, de início, que a materialidade delitiva está em comprovada, o que se afirma diante do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de constatação, principalmente, do Laudo de Exame Químico-Toxicológico definitivo, além da prova oral produzida no curso do feito. De outro lado, não há prova de autoria do crime de tráfico de drogas, senão que, apenas, comprovou-se que o acusado efetivamente mantinha a droga apreendida em seu poder por ocasião da abordagem policial e flagrante, mas que se cuidava de droga para uso próprio. Destaque-se, desde já, não ser hipótese de absolvição, pois a despeito da negativa do agente de que estivesse com a droga, ao afirmar em seu interrogatório que desconhece o entorpecente apreendido e que não estava portando nada de ilícito, a prova dos autos, não contrastada por prova em sentido contrário, é no sentido de que a maconha e cocaína apreendidos estavam, sim, em poder do acusado. Observe-se que, ao ser ouvido em juízo, o Policial Civil Marivaldo de Araújo afirmou que estava na companhia do policial Jatniel fazendo diligências na região central da cidade, em busca de indivíduos que atuam na área com tráfico de drogas, furto etc. Avistaram o acusado e realizaram abordagem, no Largo do Paissandú. Em revista pessoal, localizaram com ele nove invólucros de maconha e quatro de cocaína, além

de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, em notas trocadas. O acusado permaneceu em silêncio. O acusado não estava vendendo nada e não estava com "rodinho" no sinal. Não viram ele vendendo drogas. Estavam diligenciando na região e pelo contexto, decidiram abordá-lo e, de fato, encontraram a droga com ele. No dia, abordaram outras pessoas, mas não encontraram nada com as outras pessoas e as liberaram. No mesmo sentido, o relato do Policial Civil Jatniel Lima dos Santos, a relatar que estavam em diligências na região central, em operação de combate ao micro tráfico, bem como a roubos e furtos, delitos praticados nas ruas, com frequência, sobretudo em sinais. Avistaram o acusado com uma sacola nas mãos. Efetuaram abordagem e encontraram com ele um pouco de maconha e cocaína e R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro. O acusado não falou nada, tendo permanecido em silêncio. O local é conhecido pelo comércio frequente de drogas. a operação visava combater o micro tráfico, além de roubos e furtos em sinais. Não se recorda se outras pessoas foram abordadas. O acusado não estava vendendo mercadorias no farol ou na rua e não estava com rodinho. O acusado, ao ser interrogado, negou a posse da droga, afirmando que não tinha nada de ilícito consigo. Negou a prática de tráfico e, até mesmo, que estivesse com drogas para uso próprio. Pois bem, a prova produzida não foi capaz de demonstrar efetivo envolvimento do réu com o narcotráfico, pelo que a desclassificação é medida que se impõe. Importante salientar que a absolvição pretendida pela defesa não se revela como possível, porquanto haja indícios veementes do envolvimento do acusado com a droga apreendida, sendo certo que os dois policiais civis ouvidos, pessoas que o detiveram com a droga apreendida, afirmaram de modo firme e coerente que a droga estava em poder dele no momento da abordagem. A negativa do acusado não conta com nenhuma prova que a ampare. Nada além de suas próprias palavras. De outro lado, não foi identificada nenhuma prática de venda e nem mesmo de movimentação suspeita de que o acusado estivesse praticando o comércio de drogas naquela ocasião. Acresce que a quantidade apreendida é perfeitamente compatível com o uso. Aliás, compatível até mesmo com o usuário ocasional de drogas, anotando-se, ainda, que o numerário apreendido é em valor bastante reduzido. Desta forma, diante da fragilidade da prova colhida no curso da instrução, não se confirmando, em nada, o acusado promovia o tráfico de drogas naquela ocasião, deve ser operada a desclassificação delitiva. Com relação a pena a ser aplicada, diante da reincidência, impõe-se a aplicação de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III, Lei nº 11.343/06). Ocorre, porém, que acusado permaneceu preso preventivamente nestes autos por cerca de seis meses, não havendo nenhuma possibilidade de não se reconhecer que a pena final, qualquer que fosse ela, está devidamente cumprida. De efeito, o acusado permaneceu por seis meses no cárcere, nestes autos, em condição própria de pena privativa de liberdade no regime fechado e sua condenação se restringe ao cumprimento de medida educativa de comparecimento a curso educativo. Não é nada justo que pague mais nada nesta ação penal. Ao revés, impõe-se o pronto julgamento de extinção da pena pelo seu cumprimento. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de DESCLASSIFICAR o crime descrito na denúncia para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e CONDENAR o acusado WILL BRAINER PEREIRA KOTTKE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, impondo, em consequência, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III, Lei 11.343/06). Entretanto, diante do efetivo cumprimento prévio, frente ao tempo de prisão preventiva já cumprido, JULGO EXTINTA A PENA, pelo seu cumprimento. Oportunamente, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência, as partes foram prontamente intimadas, nesta ocasião. As partes assim se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação: Ministério Público: não apelou; Defesa: não apelou; Réu: não apelou. Certifico o trânsito em julgado às partes, ocorrido nesta data. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito, foi deliberado: 1. "Certidão retro: Anote-se no sistema; 2. Observado que não se trata de narcotráfico, defiro o levantamento do numerário apreendido nestes autos pelo acusado. Expeça-se Mandado de Levantamento Judicial Eletrônico em seu favor. 3. Defiro expressamente a justiça gratuita ao acusado, assistido pela Defensoria Pública. 4. Diante da extinção da pena, acima proclamada, com as cautelas de praxe,

arquivem-se os autos". Por último, ante as declarações do réu durante seu interrogatório informando que esta sendo ameaçado e oprimido em sua carceragem, oficie-se à direção do estabelecimento prisional em que o acusado encontra-se custodiado (CDP de Pinheiros II), a fim de informar que, ao ser interrogado na data de hoje, noticiou que está sendo ameaçado e oprimindo por outros detentos, estando com receio de sofrer consequências e que não pode sequer retornar para a cela em que está, postulando transferência para o seguro, com a observação de que este Juízo apenas está a transmitir aquilo que foi relatado pelo réu, ficando, por evidente, a critério da SAP a eventual apuração da veracidade dos fatos e da possibilidade ou não de remoção para outro setor. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.